

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（一）

第二十八講 解釋要旨 參政權

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈參政權〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第一屆（37.07～47.08：釋字 1～79）			
31 (43.01.29)	憲 §65 規定立法委員之任期為三年，§93 規定監察委員之任期為六年，該項任期本應自其就職之日起，至屆滿憲法所定之期限為止。惟值國家發生重大變故，事實上不能依法辦理次屆選舉時，若聽任立法監察兩院職權之行使陷於停頓，則顯與憲法樹立五院制度之本旨相違。故在第二屆委員未能依法選出集會與召集以前，自應仍由第一屆立法委員、監察委員繼續行使其職權。	§§65, 93 [釋 261] [釋 499]	[國民主權原則] [情事變遷 & 選舉權之剝奪] Q 本件何以不見有關國大代表任期之釋示？
187 (73.05.18)	公務人員依法辦理退休請領退休金，乃行使法律基於憲法規定所賦予之權利，應受保障。其向原務機關請求核發服務年資或未領退休金之證明，未獲發給者，在程序上非不得依法提起訴願或行政訴訟。	[釋 266] [釋 312] [釋 575]	[公法上財產請求權] 退休金] [訴訟權] Q 何謂「基於憲法規定所賦予之權利」？ Ω 基於應考試服公職權所衍生之制度性保障所賦予之公法上財產請求權。
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
201 (75.01.03)	〈解釋理由書〉 按公務人員依法辦理退休請領退休金，乃行使法律基於憲法規定所賦予之權利，應受保障。	§15 [釋 187] [釋 246] [釋 266] [釋 312] [釋 575]	[公法上財產請求權] 退休金] [訴訟權] Q 基於憲法什麼規定？所賦予之什麼權利？

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
246 (78.09.29)	行政院訂頒之全國軍公教人員待遇支給辦法第七條對工作津貼及軍職幹部服勤加給、主官獎助金，不列入退休（役）保險俸額內計算，以及對於不服勤人員不予支給加以規定，乃係斟酌國家財力、人員服勤與否或保險費繳納情形等而為者，尚未逾越立法或立法授權之裁量範圍，與憲法並無抵觸。至行政院行政院台 59 人政肆字第 17897 號函載「因案停職人員在停職期間，既未正式服勤，關於停職半薪及復職補薪，均不包括工作補助費計支」，則係兼顧有服勤工作始應支給補助費之特性所為之說明，與憲法亦無抵觸。	§15 [釋 575]	[公法上財產請求權_範圍] [應考試服公職權_制度性保障]
261 (76.06.21)	中央民意代表之任期制度為憲法所明定，第一屆中央民意代表當選就任後，國家遭遇重大變故，因未能改選而繼續行使職權，乃為維繫憲政體制所必要。惟民意代表之定期改選，為反映民意，貫徹民主憲政之途徑，而本院釋字第三十一號解釋、憲法第二十八條第二項及動員戡亂時期臨時條款第六項第二款、第三款，既無使第一屆中央民意代表無限期繼續行使職權或變更其任期之意，亦未限制次屆中央民意代表之選舉。事實上，自中華民國五十八年以來，中央政府已在自由地區辦理中央民意代表之選舉，逐步充實中央民意機構。為適應當前情勢，第一屆未定期改選之中央民意代表除事實上已不能	[釋 31] [釋 499]	[國民主權原則] [情事變遷與選舉權之恢復] Q 釋字 31 與 261 之論理一貫？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
261 (續)	行使職權或經常不行使職權者，應即查明解職外，其餘應於中華民國八十年十二月三十一日以前終止行使職權，並由中央政府依憲法之精神、本解釋之意旨及有關法規，適時辦理全國性之次屆中央民意代表選舉，以確保憲政體制之運作。		
	〈解釋理由書〉 中央政府自應依憲法之精神、本解釋之意旨及有關法規，妥為規劃，在自由地區適時辦理含有全國不分區名額之次屆中央民意代表選舉，以確保憲政體制之運作。至現有增加名額選出之中央民意代表其職權之行使，仍至任期屆滿時為止，併此說明。		[全國不分區代表之由來]
266 (79.10.05)	公務人員基於已確定之考績結果，依據法令規定為財產上之請求而遭拒絕者，影響人民之財產權，得依法提起訴願或行政訴訟。	§§15, 16 [釋 187] [釋 312]	[公法上財產請求權 _考績獎金] [訴訟權] Q 如何侵害財產權？
268 (79.11.09)	中華民國五十一年八月廿九日修正公布之考試法第七條規定：「公務人員考試與專門職業及技術人員考試，其應考資格及應試科目相同者，其及格人員同時取得兩種考試之及格資格」，如認此項規定有欠周全，應先修正法律，而在法律未修正前，考試院於中華民國七十一年六月十五日修正發布之考試法施行細則第九條第二項則規定：「公務人員考試及	§18	[法律保留原則] [法律優位原則] Q 關於考試院所作之決定(「考試行為」)，大法官何以允許適度放寬「法律保留」原則(釋字 155 參見)，而仍嚴守「法律優位」原則？

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
268 (續)	格人員，同時取得專門職業及技術人員考試及格資格者，其考試總成績，須達到專門職業及技術人員考試之錄取標準」，增設法律所無之限制，顯與前述法律使及格人員同時取得兩種資格之規定不符，並有違憲法保障人民權利之意旨，依憲法第一百七十二條之規定，應不予適用。 ❶ 考試法業於 75/01/24 廢止。		Q 所謂「憲法保障人民權利之意旨」，意指？
290 (81.01.24)	動員戡亂時期公職人員選舉罷免法（78/02/03 修正公布）§32-I 有關各級民意代表候選人學、經歷之限制，與憲法尚無牴觸。惟此項學、經歷之限制，應隨國民之教育普及加以檢討，如認為仍有維持之必要，亦宜重視其實質意義，並斟酌就學有實際困難者，而為適當之規定，此當由立法機關為合理之裁量。 ❶ 80/08/02 動員戡亂時期公職人員選舉罷免法更名為「公職人員選舉罷免法」；89/11/01 修正，刪除前揭規定。	§17 [釋 340] [釋 468]	[參選限制_學經歷] Q 法律漏未「斟酌就學有實際困難者，而為適當之（例外）規定」，何以尚非違憲？其殆採哪種審查基準？ Ω 國家關於「平等權」之保護義務與其對於「其他憲法權利」之保護義務有別？對參選權設學經歷限制既不違憲，其未設例外自不違憲？
312 (82.01.29)	公務人員退休，依據法令規定請領福利互助金，乃為公法上財產請求權之行使，如遭受損害時，得依訴願或行政訴訟程序請求救濟。	§§15, 16 [釋 187] [釋 201] [釋 266]	[公法上財產請求權_福利互助金] [訴訟權]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
312 (續)	〈解釋理由書〉 人民財產權不應因其被任命為公務人員，與國家發生公法上之忠勤服務關係而受影響。公務人員之財產權，不論其係基於公法關係或私法關係而發生，國家均應予以保障，如其遭受損害，自應有法律救濟途徑，方符憲法第八十三條保障公務人員之意旨。	§83	[財產權→ 訴訟權]
331 (82.12.30)	僑居國外國民及全國不分區之中央民意代表，係按該次選舉政黨得票總數比例方式產生，而非由選舉區之選民逕以投票方式選出，自無從由選舉區之選民以投票方式予以罷免...惟此種民意代表如喪失其所由選出之政黨黨員資格時，自應喪失其中央民意代表之資格，方符憲法增設此一制度之本旨。	1991 增修 §4 [釋 401]	[政黨比例代表之罷免] Q 對於不分區代表出任立法院長者，其罷免亦適用本號解釋？
340 (83.02.25)	公職人員選舉罷免法 §38-II：「政黨推薦之區域、山胞候選人，其保證金減半繳納。但政黨撤回推薦者，應全額繳納」無異使無政黨推薦之候選人，須繳納較高額之保證金，形成不合理之差別待遇，與憲法 §7 之意旨有違，應不再適用。 ① 83/07/23 公職人員選罷法修正，刪除系爭差別待遇。	§§7, 17 [釋 290] [釋 468]	[參選保證金制度] Q 法律規定不同的「參選保證金」乃違反「平等權」（參政權之平等保護）？或過度限制「參政權」而違反「比例原則」？

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第六屆（83.10～92.9：釋字 367～566）			
401 (85.04.26)	罷免權乃人民參政權之一種，憲法§133 規定被選舉人得由原選舉區依法罷免之。則國民大會代表及立法委員因行使職權所為言論及表決，自應對其原選舉區之選舉人負政治上責任。從而國民大會代表及立法委員經國內選舉區選出者，其原選舉區選舉人得以國民大會原選舉區選舉人得以國大代表及立法委員所為言論及表決不當為理由，依法罷免之，不受憲法 §§32, 73 規定之限制。	§§32, 73, 133 [釋 331]	[言論免責特權 & 罷免權之關係] Ω 言論免責特權僅免除國代之法律責任，俾便其行使職權，但未免除其政治責任，使其無庸對選民負責。
434 (86.07.25)	公務人員保險法規定之保險費，係由被保險人與政府按一定之比例負擔，以為承保機關保險給付之財務基礎。該項保險費，除為被保險人個人提供保險給付之資金來源外，並用以分擔保險團體中其他成員之危險責任。是保險費經繳付後，該法未規定得予返還，與憲法並無牴觸。惟被保險人所繳付之保險費中，關於養老保險部分，承保機關依財政部核定提存準備辦法規定，應提撥一定比率為養老給付準備，此項準備之本利類似全體被保險人存款之累積。公務人員保險法於第十六條第一項關於養老給付僅規定依法退休人員有請領之權，對於其他離職人員則未規定，與憲法第十五條保障人民財產權之意旨不符，應即檢討修正。	§15 [釋字 285]	[公法上財產請求權—公保養老給付] Q 本件與釋字 285 何以不同？公保養老給付何以非屬立法裁量範圍？ Cf. 釋字 280

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
434 (續)	① 公務人員保險法於 88/05/29 更名為公教人員保險法，並修正全文，規定凡依法退休、資遣或繳付保險費滿 15 年並年滿 55 歲而離職退保者，均得請求養老給付。		
442 (86.12.12)	憲法 §16 規定人民有訴訟之權，旨在確保人民得依法定程序提起訴訟及受公平之審判。至於訴訟救濟應循之審級制度及相關程序，立法機關自得衡量訴訟性質以法律為合理之規定。公職人員選舉罷免法（83/07/23）§109 規定，選舉訴訟採二審終結不得提起再審之訴，係立法機關自由形成之範圍，符合選舉訴訟事件之特性，於憲法保障之人民訴訟權尚無侵害，且為增進公共利益所必要，與憲法 §23 亦無牴觸。	§16	[選舉訴訟制度之立法裁量] [正當司法程序] Q 本件採取哪種審查基準？「符合選舉訴訟事件之特性」意指「合理相關」？抑或「實質相關」？
468 (87.10.22)	總統副總統選舉罷免法 §23-II & IV 有關連署保證金規定，係表達被連署人有相當程度之政治支持，藉與政黨推薦候選人之要件相平衡，並防止人民任意參與總統、副總統之候選，耗費社會資源，在合理範圍內所為適當之規範，尚難認為對總統、副總統之被選舉權為不必要之限制，與憲法規定之平等權亦無違背。同條第一項連署保證金新台幣一百萬元之規定，並未逾越立法裁量之範圍，與憲法 §23 規定尚無違背。	§§17, 46, 129 [釋 290] [釋 340]	[連署保證金] Q 連署制度必須有連署保證金以為配合？ Q 連署保證金之金額須合理？ Q 本件解釋係基於何種民主理論？

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
481 (88.04.16)	憲法增修條文（81/05/28）§17 授權以法律訂定省縣地方制度，同條第一款、第三款規定，省設省議會及省政府，省置省長一人，省議員與省長分別由省民選舉之，係指事實上能實施自治之省，應受上述法律規範，不受憲法相關條文之限制。省縣自治法遂經憲法授權而制定，該法 §64 規定，轄區不完整之省，其議會與政府之組織，由行政院另定之。行政院據此所訂定之福建省政府組織規程，未規定由人民選舉省長及省議會議員，乃斟酌福建省之特殊情況所為之規定，為事實上所必需，符合母法授權之意旨，與憲法 §7 人民在法律上平等之原則亦無違背。	§7； 1992 二次增修 §17	[選舉權限制] Q 本件亦本「情事變遷」原則？
483 (88.05.14)	公務人員依法銓敘取得之官等俸級，非經公務員懲戒機關依法定程序之審議決定，不得降級或減俸，此乃憲法上服公職權利所受之制度性保障。公務人員任用法第十八條第一項第三款前段規定：「經依法任用人員，除自願者外，不得調任低一官等之職務；在同官等內調任低職等職務者，仍以原職等任用」，有任免權之長官固得據此將高職等之公務人員調任為較低官等或職等之職務；惟一經調任，依公務人員俸給法第十三條第二項及同法施行細則第七條之規定，此等人員	§18	[公務員身份之制度性保障_官等俸級]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
483 (續)	其所敘俸級已達調任職等年功俸最高級者，考績時不再晉敘，致高資低用人員縱於調任後如何戮力奉公，成績卓著，又不論其原敘職等是否已達年功俸最高級，亦無晉敘之機會，則調任雖無降級或減俸之名，但實際上則生類似降級或減俸之懲戒效果，與首開憲法保障人民服公職權利之意旨未盡相符，主管機關應對上開公務人員任用法、公務人員俸給法及附屬法規從速檢討修正。 ① 公務人員俸給法於 91/06/26 修正，將原 §13 改列為 §16，並修正 §16-II：「在同官等內調任低職等職務仍以原職等任用，並敘原俸級人員，考績時得在原銓敘審定職等俸級內晉敘」。		
491 (88.10.15)	公務人員考績法第十二條第一項第二款規定各機關辦理公務人員之專案考績，一次記二大過者免職。同條第二項復規定一次記二大過之標準由銓敘部定之，與上開解釋意旨不符。 對於公務人員之免職處分既係限制憲法保障人民服公職之權利，自應踐行正當法律程序，諸如作成處分應經機關內部組成立場公正之委員會決議，處分前並應給予受處分人陳述及申辯之機會，處分書應附記理由，並表明救濟	§§18, 23	[服公職權_正當程序保障_實質正當（法律保留原則）] [程序正當] Q 剝奪服公職權應遵循之正當程序（「程序正當」）與剝奪人身自由之正當程序（「程序正當」）有無不同？

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
491 (續)	方法、期間及受理機關等，設立相關制度予以保障。復依公務人員考績法第十八條規定，服務機關對於專案考績應予免職之人員，在處分確定前得先行停職。受免職處分之公務人員既得依法提起行政爭訟，則免職處分自應於確定後方得執行。 ① 90/06/20 公務人員考績法修正 §16，明定得一次記兩大過之事由；§18 明定免職處分自確定之日起執行；§14 增訂 III 項：「考績委員會對於擬予考績列丁等及一次記二大過人員，處分前應給予當事人陳述及申辯之機會」。		
499 (89.03.24)	第三屆國民大會通過之憲法增修條文(88/09/04) §1 規定，國民大會代表第四屆起依比例代表方式選出，並以立法委員選舉各政黨所推薦及獨立參選之候選人得票之比例分配當選名額，係以性質不同、職掌互異之立法委員選舉計票結果，分配國民大會代表之議席，依此種方式產生之國民大會代表，本身既未經選舉程序，僅屬各黨派按其在立法院席次比例指派之代表，與憲法 §25 國民大會代表全國國民行使政權之意旨，兩不相容。	1999 增修 §1	[國民主權原則] Q 何以國大不得改制為「全額」政黨比例制代表？
546 (91.05.31)	院字第二八一〇號解釋：「依考試法舉行之考試，對於應考資格	§§16, 17	[權利保護必要性_原告適格]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
546 (續)	體格試驗，或檢覈經決定不及格者，此項決定，自屬行政處分。其處分違法或不當者，依訴願法第一條之規定，應考人得提起訴願。惟為訴願決定時，已屬無法補救者，其訴願為無實益，應不予受理，依訴願法第七條應予駁回。」人民申請為公職人員選舉候選人時，因主管機關認其資格與規定不合，而予以核駁，申請人不服提起行政爭訟，雖選舉已辦理完畢，但人民之被選舉權，既為憲法所保障，且性質上得反覆行使，若該項選舉制度繼續存在，則審議或審判結果對其參與另次選舉成為候選人資格之權利仍具實益者，並非無權利保護必要者可比，此類訴訟相關法院自應予以受理，本院上開解釋，應予補充。		Q 得反覆行使之權利，其權利保護必要應為不同之認定？
新制（92.10～：釋字 567～）			
575 (93.04.02)	憲法第十八條規定人民有服公職之權利，旨在保障人民有依法令從事於公務，暨由此衍生享有之身分保障、俸給與退休金等權利。機關因改組、解散或改隸致對公務人員之憲法所保障服公職之權利產生重大不利影響，應設適度過渡條款或其他緩和措施，以資兼顧。	§18 [釋 715]	[服公職權之意涵] Q 「服公職」與「應考試」之關係？
583 (93.09.17)	公務員懲戒法第二十五條第三款規定，懲戒案件自違法失職行為終了之日起，至移送公務員懲戒委員會之日止，已逾十年者，公	§§18, 23 [釋 491]	[服公職權之限制]

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
583 (續)	務員懲戒委員會應為免議之議決。公務人員經其服務機關依公務人員考績法（79/12/28）十二條第一項第二款規定所為免職之懲處處分，實質上屬於懲戒處分，為限制人民服公職之權利，未設懲處權行使期間，有違前開意旨。為貫徹憲法上對公務員權益之保障，有關公務員懲處權之行使期間，應類推適用公務員懲戒法相關規定。又查公務員懲戒法概以十年為懲戒權行使期間，未分別對公務員違法失職行為及其懲戒處分種類之不同，而設合理之規定，與比例原則未盡相符，有關機關應就公務員懲戒構成要件、懲戒權行使期間之限制通盤檢討修正。公務人員考績法有關懲處之規定亦應一併及之，附此指明。 ❶ 公務人員考績法迄(104/09)未修正。		
611 (95.05.26)	中華民國八十五年十二月十日修正發布之公務人員任用法施行細則，係依公務人員任用法第三十九條授權所訂定，該細則第十五條第二項規定「本法第十七條第四項所稱『薦任第七職等以下職務』，指職務之列等最高為薦任第七職等者而言」，乃主管機關就同年十一月十四日修正公布之公務人員任用法第十七條第四項	§§18, 23	[服公職權] ❶ 系爭函釋何以「尚在母法合理解釋範圍之內」？ Vgl. 釋字 692（該號解釋是否過苛）？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
611 (續)	規定所為補充性之解釋，尚在母法合理解釋範圍之內，與憲法第十八條保障人民服公職權利及第二十三條法律保留原則均無違背。		Cf. 釋字 692 系爭「在校就學」函釋，何以違反「一般法律解釋方法」？
614 (95.07.28)	公務人員曾任公營事業人員者，其服務於公營事業之期間，得否併入公務人員年資，以為退休金計算之基礎，憲法雖未規定，立法機關仍非不得本諸憲法照顧公務人員生活之意旨，以法律定之。在此類法律制定施行前，主管機關依法律授權訂定之法規命令，或逕行訂定相關規定為合理之規範以供遵循者，因其內容非限制人民之自由權利，尚難謂與憲法第二十三條規定之法律保留原則有違。惟曾任公營事業人員轉任公務人員時，其退休相關權益乃涉及公共利益之重大事項，仍應以法律或法律明確授權之命令定之為宜，併此指明。	§§7, 18, 23 [釋 443] [釋 542] [釋 575]	[授益行政 & 法律保留]
618 (95.11.03)	兩岸關係條例第二十一條第一項前段規定，大陸地區人民經許可進入臺灣地區者，非在臺灣地區設有戶籍滿十年，不得擔任公務人員部分，乃係基於公務人員經國家任用後，即與國家發生公法上職務關係及忠誠義務，其職務之行使，涉及國家之公權力，不僅應遵守法令，更應積極考量國	§§7, 18； 2005 七次增修 §11 [釋 205] [釋 371] [釋 572] [釋 590]	[應考試服公職權_大陸地區人民] [平等權] Q 本件乃違反「平等權」或「比例原則」？ Q 本件實際殆採取哪種審查基準？

28 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
618 (續)	家整體利益，採取一切有利於國家之行爲與決策；並鑒於兩岸目前仍處於分治與對立之狀態，且政治、經濟與社會等體制具有重大之本質差異，爲確保臺灣地區安全、民眾福祉暨維護自由民主之憲政秩序，所爲之特別規定，其目的洵屬合理正當。 考量原設籍大陸地區人民對自由民主憲政體制認識之差異，及融入臺灣社會需經過適應期間，且爲使原設籍大陸地區人民於擔任公務人員時普遍獲得人民對其所行使公權力之信賴，尤需有長時間之培養，系爭規定以十年爲期，其手段仍在必要及合理之範圍內，立法者就此所爲之斟酌判斷，尙無明顯而重大之瑕疵。		
645 (97.07.11)	公民投票法第十六條第一項規定：「立法院對於第二條第二項第三款之事項，認有進行公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後，交由中央選舉委員會辦理公民投票。」旨 在使立法院就重大政策之爭議，而有由人民直接決定之必要者，得交付公民投票，由人民直接決定之，並不違反我國憲政體制爲代議民主之原則，亦符合憲法主權在民與人民有創制、複決權之意旨；此一規定於立法院行使憲法所賦予之權限範圍內，且不違反憲法權力分立之基本原則下，與憲法尙無牴觸。	§§2, 17, 136, 174-(2)； 2005 七次增修 §§1, 12 [釋 342] [釋 520]	[政策公投_發動]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
682 (99.11.19)	中華民國九十年七月二十三日修正發布之專門職業及技術人員考試法施行細則第十五條第二項規定：「前項總成績滿六十分及格……者，若其應試科目有一科成績為零分、專業科目平均不滿五十分、特定科目未達規定最低分數者，均不予及格。」專門職業及技術人員考試總成績計算規則第三條第一項規定：「……採總成績滿六十分及格……者，其應試科目有一科成績為零分，或專業科目平均成績不滿五十分，或特定科目未達規定最低分數者，均不予及格」…及九十年七月二十五日修正發布之專門職業及技術人員特種考試中醫師考試規則第九條第三項規定：「本考試應試科目有一科成績為零分或專業科目平均成績未滿五十分或專業科目中醫內科學成績未滿五十五分或其餘專業科目有一科成績未滿四十五分者，均不予及格。」尚未牴觸憲法第二十三條法律保留原則、比例原則及第七條平等權之保障，與憲法第十五條保障人民工作權及第十八條保障人民應考試權之意旨無違。 〈解釋理由書〉 憲法第十八條對人民應考試權之規定，除保障人民參加考試取得公務人員任用資格之權利外，亦包含人民參加考試取得專門職業	§§7, 15, 18, 23, 86-(2) [釋 547]	[應考試服公職權_限制] Q 本件為「人權案件」或「權力分立」案件？
			[權力分立_相互尊重] 爰採「低密度」審查

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
682 (續)	及技術人員執業資格之權利，以符憲法保障人民工作權之意旨。又為實踐憲法保障人民應考試權之意旨，國家須設有客觀公平之考試制度，並確保整體考試結果之公正。對於參加考試資格或考試方法之規定，性質上如屬應考試權及工作權之限制，自應符合法律保留原則、比例原則及平等權保障等憲法原則。惟憲法設考試院賦予考試權，由總統提名、經立法院同意而任命之考試委員，以合議之方式獨立行使，旨在建立公平公正之考試制度；就專門職業人員考試而言，即在確保相關考試及格者具有執業所需之知識與能力，故考試主管機關有關考試資格及方法之規定，涉及考試之專業判斷者，應給予適度之尊重，始符憲法五權分治彼此相維之精神。		
715 (102.12.20)	中華民國九十九年國軍志願役專業預備軍官預備士官班考選簡章壹、二、（二）規定：「曾受刑之宣告……者，不得報考。……」與憲法第二十三條法律保留原則無違。惟其對應考試資格所為之限制，逾越必要程度，牴觸憲法第二十三條比例原則，與憲法第十八條保障人民服公職之權利意旨不符。相關機關就嗣後同類考試應依本解釋意旨妥為訂定招生簡章。		[應考試服公職權_限制]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
715 (續)	過失犯因疏忽而觸法，本無如同故意犯罪之惡性可言，苟係偶然一次，且其過失情節輕微者，難認其必然欠缺應具備之服役品德、能力而影響國軍戰力。系爭規定剝奪其透過系爭考選以擔任軍職之機會，非屬達成目的之最小侵害手段，逾越必要程度，牴觸憲法第二十三條比例原則，與憲法第十八條保障人民服公職之權利意旨不符。		Q 本件「比例原則」部分，採取哪種審查基準？
	〈湯德宗大法官部分協同暨部分不同意見書〉 「應考試服公職」之權載在憲法第十八條，緊接於憲法第十七條「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」之後，乃「參政權」(political rights) 之一種。按所謂「服公職權」，自比較憲法例觀之，即「平等參與公共服務之權」(the right of equal access to public service)，或稱「參與公共生活及服務之權」(right to participate in public life and service)，旨在保障公民有依平等之條件，參與公共服務的權利。		[應考試服公職權定性]
	「應考試服公職」權旨在保障人民有「經由公開競爭之程序」，以取得公部門職位，參與行使國家統治權力的權利。「應考試」既為取得「服公職」之資格，則憲法第十八條之「應考試服公職」權並非保障人民有為其他（「服公職」以外之）目的而「應考試」		[應考試服公職權_是一非二]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
715 (續)	的權利；反之，「服公職」之資格尚可無需「應考試」而取得者，該公職即非屬憲法第十八條「應考試服公職」權之保障範圍。是以經由「選舉」產生之民意代表，或經由「政治任命」程序（如經總統提名與立法院同意）產生之政務人員，一般雖亦以「公職人員」稱之，但其並非「應考試服公職」權所保障之「公職」範圍。		
	所謂「考試」允宜依據憲法第八十五條之精神，從實質上解釋為「公開競爭之程序」，而不限於考試院依據憲法所舉辦之國家考試。尤其，「應考試服公職」權載在憲法第二章，乃人民受憲法保障之基本權利之一，其與憲法第八章所規定之考試院職掌，本無必然關係—兩章雖同稱「考試」，其意涵大可不同。		[考試之意涵]
	憲法因採「文武分治」原則，職業軍人之養成（軍事教育）迄為國家所獨占（與常任文官之循多元管道養成者迥異），並強調教育、訓練、任用一以貫之。受預備軍官或預備士官基礎教育期滿成績合格者隨即分別以少尉或下士任官分發，無需再經任官考選程序，是以系爭考選簡章關於系爭職業軍人（常任武官）「入學考試」應試資格之消極限制，其作用殆與公務人員（常任文官）「任用資格考試」應試資格之消極限制相當。兩者時間序列雖有		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
715 (續)	前後之別，但其阻絕有志者經由競爭程序，參與公共服務（擔任文、武公職）之作用，並無不同。因此，應認系爭軍官、士官班「入學考試」亦「應考試服公職」權所保障之（任用）「考試」範圍。		
	「應考試服公職」權所保護之利益雖不若生命或身體自由重要，惟鑑於其關係公共生活（public life）之形塑，對於參政權之限制應適用普通密度之法律保留，亦即應由法律直接規定，或以法律明確授權之命令規定。		[法律保留原則_相對保留]
	系爭規定重大影響人民「應考試服公職」之權，與（釋字第六八二號解釋所牽涉之）考試科目、及格方式等規定不可同日而語，非僅屬執行法律之細節性、技術性次要事項，而得由主管機關逕自發布命令為必要之規範。		